

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5805/2544

พนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
นายโกวิท วงศาางาม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 195

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 21, มาตรา 39 ทวิ, มาตรา 40 (1), มาตรา 41, มาตรา 42

ตามที่ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 21 บัญญัติว่า ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ การที่จำเลยให้ นายช่างเทศบาลเขียนแบบแปลนให้ไม่ใช้การดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ จำเลยมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ย่อมต้องรู้ว่าการก่อสร้างอาคารต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากทางราชการหรือดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ ก่อน แต่จำเลยกลับทำการก่อสร้างไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การก่อสร้างของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา แม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยก่อนหน้านั้นไม่เป็นความผิด

จำเลยได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีให้ระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2539 โดย ลูกจ้างของจำเลยเป็นผู้รับแทน และเมื่อพนักงานสอบสวนไปตรวจที่เกิดเหตุในวันที่ 2 ตุลาคม 2539 ก็พบคนงานกำลังก่อสร้างอาคารพิพาทอยู่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 รวมเป็น

เวลา 121 วัน แต่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยฝ่าฝืนคำสั่ง 120 วัน นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยอยู่
แล้ว และเมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐาน ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานท้องถิ่นเพียง
120 วัน ทั้งฟ้องว่าระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 (รวม
เวลา 129 วัน) จำเลยก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษปรับจำเลยรายวันตลอดมาจนถึงวันฟ้องและหลังจากวัน
ฟ้องจนกว่าจำเลยจะปฏิบัติให้ถูกต้องจึงไม่ชอบ เพราะเมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำ
ผิดดังกล่าวเพียงถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2539 แสดงว่าหลังจากวันนั้นจำเลยอาจมิได้
ฝ่าฝืนคำสั่งหรือได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว การลงโทษปรับจำเลยหลังจากวันนั้นจึง
เป็นการพิพากษาเกินคำขอและเกินไปกว่าที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ไม่ชอบตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 192 ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็น
ควรพิพากษาแก้โทษจำเลยให้ถูกต้องตรงกับคำฟ้อง

การที่จำเลยทำการก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 อันเป็นการ
กระทำผิดสำเร็จแล้ว และมาตรา 40 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการก่อสร้างโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ สั่งให้ระงับการ
ก่อสร้างและพิจารณาสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี การสั่งตาม
มาตรา 41 หรือมาตรา 42 หมายถึงการสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและหาก
เจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนได้ แต่โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยรื้อถอนจึงไม่ต้อง
พิจารณาว่ากรณีของจำเลยเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือไม่
เมื่อจำเลยก่อสร้างโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้จำเลย
ระงับการก่อสร้าง แต่จำเลยทราบคำสั่งแล้วจำเลยยังคงก่อสร้างต่อไปจำเลยย่อมมี
ความผิดตามมาตรา 40 (1) และกรณีนี้มีใช้กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังว่า การกระ

ทำดังกล่าวของจำเลยไม่เป็นความผิด จึง ไม่มีอาจนาบทบัญญัติมาตรา 2 วรรคสอง แห่ง ป.อ. มาบังคับได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒, ๓, ๔, ๒๑, ๔๐, ๖๕, ๖๗, ๗๐, ๗๙, ๘๐ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ และนับโทษจำเลยต่อจากโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๑๐๙/๒๕๔๐ ของศาลชั้นต้น ให้จำเลยและบริวารออกจากทาง สาธารณประโยชน์ และปรับจำเลยตามกฎหมาย จนกว่าจำเลยจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑, ๔๐ (๑) , ๖๕ วรรคหนึ่ง , วรรคสอง , ๖๗ วรรคหนึ่ง , วรรคสอง , ๗๐ ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙ (๑) , ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง , วรรคสี่ เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐาน ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กและอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๑ คูหา เพื่อพาณิชย์กรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นความผิดกรรมเดียวกัน จำคุก ๒ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวันวันละ ๑๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ถึงวันพิพากษา เป็นเงิน ๑๐๗,๕๐๐ บาท กับให้ปรับรายวันอีกวันละ ๑๐๐ บาท นับแต่วันพิพากษาลงเวลาที่จำเลยฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจำคุก ๔ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวันวันละ ๑๐๐

บาท นับแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๕ ถึงวันพิพากษา เป็นเงิน ๑๐๖,๗๐๐ บาท กับให้
ปรับต่อไปอีกวันละ ๑๐๐ บาท นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไปตลอดระยะเวลา
เวลาที่จำเลยยังคงฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ?

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? พิจารณาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของ
จำเลย ว่า จำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิดที่มีได้ยื่นแบบแปลนขออนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยให้นายช่างเทศบาลจังหวัด
ยโสธรเป็นผู้เขียนแบบแปลนการก่อสร้างโดยได้รับคำแนะนำจากนายช่างดังกล่าวว่า
ให้ก่อสร้างไปก่อน แล้วจึงไปยื่นแบบแปลนได้ในภายหลัง จำเลยจึงก่อสร้างไปก่อน
โดยเข้าใจว่าสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายและเมื่อนายวิชัย โสธรวงศ์
พนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ตำแหน่งช่างโยธา ๓ แนะนำให้จำเลยไปขออนุญาต
จำเลยก็ได้ยื่นแบบแปลนตามเอกสารหมายเลข ล.๒ ไปยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลเมือง
ยโสธร จึงเป็นการขาดเจตนาในการกระทำความผิด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ บัญญัติว่า ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการ
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ดังนั้น ในกรณีที่จำเลยก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ ดังกล่าว จำเลย ก็ต้องดำเนินการ
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ คือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบและแผนผังบริเวณ แบบแปลน เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยื่นออกไปรับแจ้งให้ การที่จำเลยให้นายช่างเทศบาล เขียนแบบแปลนให้จึงไม่ใช่การดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ซึ่งจำเลยมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ย่อมต้องรู้ว่าการก่อสร้างอาคารต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากทางราชการหรือดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ ก่อน แต่จำเลยกลับทำการก่อสร้างไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การก่อสร้างของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการกระทำผิดโดยเจตนา แม้ต่อมาภายหลังจำเลยจะไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยก่อนหน้านั้นไม่เป็นความผิด

จำเลยฎีกาต่อไปว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจำนวน ๑๒๐ วันนั้นไม่ถูกต้อง เพราะขัดกับคำให้การของนายวิชัย โสธรวงษ์ ตามเอกสารหมาย จ.๓ ซึ่งให้การว่า จำเลยทำการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพียง ๑๑ วันและไม่รื้อถอนตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพียง ๑๑ วัน นั้น เห็นว่า การรับฟัง ข้อเท็จจริงนั้น ศาลต้องพิเคราะห์จากพยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมดในสำนวนมิใช่พิจารณาเฉพาะข้อความเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร คดีนี้ โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรให้ระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทตามเอกสารหมาย จ.๕ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยลูกจ้างของจำเลยเป็นผู้รับแทน ต่อมานายวิชัยตรวจสอบอาคารของจำเลยอีกครั้งพบว่าจำเลยยังฝ่าฝืนทำการก่อสร้างต่อไป จึงทำรายงานผู้บังคับบัญชาตามเอกสารหมาย จ.๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และเมื่อร้อยตำรวจเอกมานิต สิทธิไพร พนักงานสอบสวนไปตรวจที่เกิดเหตุในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ก็พบคนงานกำลังก่อสร้างอาคารพิพาทอยู่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ รวมเป็นเวลา ๑๒๑ วัน แต่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยฝ่าฝืนคำสั่ง ๑๒๐ วัน นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้ว และเมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพียง ๑๒๐ วัน ทั้งฟ้องว่าระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ (รวมเวลา ๑๒๙ วัน) จำเลยก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับ ใบ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษปรับจำเลยรายวันตลอดมาจนถึงวันฟ้องและหลังจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น คำพิพากษาส่วนนี้จึงไม่ชอบ เพราะเมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดดังกล่าวเพียงถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ แสดงว่าหลังจากวันนั้นจำเลยอาจมิได้ฝ่าฝืนคำสั่งหรือได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว การลงโทษปรับจำเลยหลังจากนั้นจึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอและเกินไปกว่าที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ ปัญหานี้แม้จำเลยมิได้ฎีกาโดยตรง แต่ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย เห็นควรพิพากษาแก้โทษจำเลยให้ถูกต้องตรงกับคำฟ้อง

จำเลยฎีกาต่อไปว่า กรณีของจำเลยเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ โดยสั่งให้จำเลยยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในภายหลังเป็นคุณแก่จำเลย ต้องนำเอากฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยมาใช้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ อันจะทำให้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดนั้น เห็นว่า การที่จำเลยทำการก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ อันเป็นการกระทำผิดสำเร็จแล้ว และมาตรา ๔๐ บัญญัติว่าในกรณีที่มีการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างและพิจารณาสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี การสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ หมายถึงการสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและหากเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนได้ แต่คดีนี้โจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยรื้อถอน จึงไม่ต้องพิจารณาว่ากรณีของจำเลยเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือไม่ เมื่อจำเลยก่อสร้างโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้จำเลยระงับการก่อสร้าง แต่

จำเลยทราบคำสั่งแล้วจำเลยยังคงก่อสร้างต่อไป จำเลยย่อมมีความผิดตามมาตรา ๔๐ (๑) และกรณีนี้มีใช้กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยไม่เป็นความผิด จึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา ๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับได้ ?

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับรายวันวันละ ๑๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ รวมเป็นเวลา ๑๒๙ วัน คิดเป็นค่าปรับ ๑๒,๙๐๐ บาท ความผิดฐาน ผ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับรายวันวันละ ๑๐๐ บาท รวม ๑๒๐ วัน คิดเป็นค่าปรับ ๑๒,๐๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-อรพินท์ เศรษฐมานิต-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

ศาลจังหวัดยโสธร - นางสาวสุนี นภาภาค

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสถิตย์ ไพเราะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ